

1504692-91.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIO YAMADA FILHO

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... segura e estreme dúvidas, a prática do tráfico de drogas pelos acusados, mas sim de outro delito. Senão vejamos.

Em Juízo, a testemunha Luiz Henrique Umel, policial militar, relatou que, na data dos fatos, ele e seu colega de farda, em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, avistaram os dois réus e mais outra pessoa em atitude suspeita. Visualizaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504692-91.2022.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504692-91.2022.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176121/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 25843954 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2176121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOILSSON APARECIDO MAGALHÃES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: MARIO YAMADA FILHO

Vistos.

JOILSSON APARECIDO MAGALHÃES DA SILVA, qualificado às fls. 22/23, e ROGÉRIO RAIMUNDO DA SILVA, qualificado às fls. 20/21, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ambos como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 29, do Código Penal c/c art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual 64.879/2020 - calamidade pública), porque, segundo a acusação, no dia 29 de junho de 2022, por volta das 20h52min, na Avenida Guido Girol, nº 405, na cidade e Comarca de Catanduva, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam droga, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, consistentes em 2 (dois) "eppendorf's" de "crack", com peso líquido de 0,1 grama, 11 (onze) "eppendorf's" de "crack", com

o peso líquido de 0,6 grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que os réus estavam na local supramencionado, próximo à travessa Cônego Oscar Serra do Amaral, quando os policiais militares, em patrulhamento de rotina, aproximaram-se do local e avistaram três indivíduos pela via pública, dentre os quais estavam os réus em situação de traficância.

O acusado ROGÉRIO foi flagrado pelos policiais enquanto entregava 1 (um) pino de "crack" a outro indivíduo, e esse último entregava o dinheiro em cédulas ao réu JOILSSON.

Em virtude da aproximação dos policiais, o terceiro indivíduo fugiu e não foi identificado, porém, logrou-se êxito na abordagem dos acusados. Em revista pessoal, verificou-se que o acusado ROGÉRIO carregava 11 (onze) "eppendorf's" contendo "crack" e R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em notas diversas. Por sua vez, o acusado JOILSSON trazia consigo 2 "eppendorf's" contendo "crack" e R\$ 502,00 (quinhentos e dois reais).

Para os policiais, o acusado ROGÉRIO afirmou que é usuário de drogas e que o dinheiro localizado era proveniente de venda de materiais para reciclagem. JOILSSON apresentou uma conversa desconexa, sem apresentar alguma justificativa para a grande quantidade de dinheiro e as drogas localizadas (fls. 161/163).

Houve prisão em flagrante (fls. 01), convertida em prisão preventiva, conforme decisão proferida em audiência de custódia, na qual foi autorizada a destruição das drogas apreendidas, bem como deferida a instauração de incidente de dependência químico-toxicológica (fs. 123/126).

Citados e notificados (fls. 177 e 179), os réus apresentaram defesa prévia, por meio de defensora nomeada (fls. 180), alegando que não há indícios de que as drogas apreendidas destinavam-se ao comércio ilícito, uma vez que a sua quantidade é pequena e o local da apreensão também é frequentado por usuários. Requereu exame para atestar a dependência toxicológica dos réus (fls. 183/187).

A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2022, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 188/189).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogados os acusados, tudo gravado em arquivos digitais constantes do próprio sistema informatizado. Na oportunidade, os réus e a Defesa desistiram da realização dos exames de dependência química (fls. 224/235).

Em alegações finais, o Ministério Público, de início, frisou que ambos os réus são portadores de maus antecedentes e reincidentes, o que deve ser levado em conta na dosimetria das penas e fixação de regime inicial fechado. Requereu a total procedência da ação penal, alegando que, não obstante os acusados tenham negado a prática do ilícito penal, os policiais militares foram firmes em narrar os fatos tal como descritos na denúncia. Argumentou que, segundo a prova oral, enquanto o acusado Rogério vendia droga, Joilsson recolhia o dinheiro, sendo apreendida considerável quantia na posse deste último (R\$ 542,00). Por fim, requereu o decreto do perdimento do dinheiro apreendido e o reconhecimento da agravante em razão de o crime ter sido cometido durante o período de calamidade pública (arquivo digital - SAJ - fls. 224/225).

Por sua vez, a Defesa dos réus alegou que as cápsulas estavam praticamente vazias, contavam com aproximadamente 7 "miligramas" (sic) de conteúdo de droga ilícita, bem como que há contradições nos depoimentos dos policiais militares. Aduziu que, segundo a prova oral produzida, o acusado Joilsson estava totalmente "alterado" (sob o efeito de drogas ou álcool), sendo improvável que ele fosse o responsável pela venda de drogas ou coleta de dinheiro. Quanto ao local ser conhecido por ser ponto de tráfico, salientou que, por óbvio, será frequentado também por usuários interessados na aquisição das drogas. Assim, requereu absolvição dos acusados por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito posse de drogas para consumo pessoal. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo, regime inicial de cumprimento menos rigoroso e afastamento da agravante sustentada pelo Ministério Público (arquivo digital - SAJ - fls. 224/225).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade de uma infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 79/81), auto de exibição e apreensão (fls. 69/70), laudo de constatação (fls. 72/74) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 144/146), os dois últimos apresentando resultados positivos para "cocaina" (na forma de "crack"). Além disso, a prova oral produzida também demonstrou a existência de infração penal (embora diversa daquela atribuída pela acusação) e de sua autoria.

Todavia, respeitada a convicção do combativo Promotor de Justiça, o conjunto probatório carreado aos autos não comprovou, de forma segura e estreme dúvidas, a prática do tráfico de drogas pelos acusados, mas sim de outro delito. Senão vejamos.

Em Juízo, a testemunha Luiz Henrique Umel, policial militar, relatou que, na data dos fatos, ele e seu colega de farda, em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, avistaram os dois réus e mais outra pessoa em atitude suspeita. Visualizaram Rogério entregando "entorpecente" a essa terceira pessoa (não abordada e não identificada), a qual, por sua vez, entregou uma cédula (aparentemente dinheiro) a Joilsson. Essa terceira pessoa se evadiu. Em revista pessoal, encontram, na posse de Rogério, R\$ 64,00 reais e 11 "pinos". Já com Joilsson foram encontrados R\$ 502,00 e 2 pinos de "crack". Na oportunidade, Rogério alegou que era usuário e vendia material reciclável. Já Joilsson estava "alterado" (possivelmente sob efeito de álcool ou drogas) e dizia frases desconexas. Acrescentou que, ao que se recorda, todos os microtubos estavam cheios de droga. Alegou não saber que tipo de cédula foi repassada pela terceira pessoa a Joilsson, argumentando que estavam a cerca de 30 metros de distância quando avistaram os réus e esse terceiro (arquivo digital - SAJ - fls. 224/225).

Em Juízo, a testemunha Diego dos Santos Costa, policial militar, relatou que é de conhecimento da Polícia Militar de Catanduva que o local dos fatos é ponto de tráfico de drogas. Em patrulhamento pelo bairro visualizaram, a cerca de 30 metros de distância, os réus entregando "algo" a um terceiro. Disse que o modus operandi dos réus era o seguinte: enquanto um dos réus (Rogério) entregava a droga, o outro (Joilsson) recolhia o dinheiro. Ao realizarem a abordagem, apreenderam 11 pinos de "crack" e R\$ 62,00 com um dos réus (Rogério), e com o outro (Joilsson) a quantia de R\$ 502,00 e mais 2 pinos de "crack". Conhecia os réus apenas de vista. Disse que todas as cápsulas (pinos) estavam cheias de droga. Na oportunidade, Rogério alegou que era usuário e Joilsson dizia frases desconexas, possivelmente sob efeito de drogas ou álcool (arquivo digital - SAJ - fls. 224/225).

Em solo policial, o réu Joilsson negou a prática da traficância, alegando que estava no local dos fatos consumindo droga com mais duas pessoas. Disse que o dinheiro apreendido em sua posse era proveniente de um consórcio. Acrescentou que não conhece Rogério e as outras pessoas que estavam no local, afirmando não saber se o primeiro estivesse vendendo drogas (fl. 7).

Em seu interrogatório judicial, o acusado Joilsson novamente negou ser verdadeira a acusação da prática de tráfico. Disse que é usuário de "crack" há 5 anos e que estava no local dos fatos consumindo droga com Rogério, uma menina e um outro rapaz. Alegou que os quatro foram abordados, mas apenas ele e Rogério foram conduzidos à repartição policial. Quando foi abordado, já havia consumido 4 pinos de "crack" e ingerido bebida alcoólica. Alegou que o dinheiro que portava (R\$ 502,00) se tratava da ajuda de familiares, sendo quatro notas de R\$ 100,00, duas de R\$ 50,00 e uma de R\$ 2,00. Alegou que estava usando o cachimbo de Rogério para consumir o "crack". Acrescentou que os policiais pegaram alguns pinos no chão, pinos esses que já tinham sido consumidos. Não conhecia os policiais militares (arquivo digital - SAJ - fls. 224/225).

Na fase extrajudicial, o acusado Rogério declarou que é usuário de "crack" e que trabalhava como colhedor de material reciclável, origem do dinheiro que portava. Negou que estivessem vendendo drogas no local. Admitiu que trazia consigo cerca de 9 pinos de "crack", destinados ao consumo pessoal. Acrescentou que pretendia consumir essa droga juntamente com Joilsson, acreditando que este também não estava vendendo drogas (fl. 6).

Em seu interrogatório judicial, o réu Rogério novamente negou ser verdadeira a acusação de tráfico. Esclareceu que havia acabado de chegar ao local dos fatos e lá já estavam mais duas pessoas usando drogas, entre eles Joilsson, "muito louco de pinga", e uma mulher. Foi para o local depois do seu trabalho como catador de material reciclável. O dinheiro apreendido era da venda realizada de reciclagem naquele dia a um "ferro velho". As cápsulas que foram apreendidas em seu poder estavam vazias e as apanhara pelo caminho, para depois trocar por drogas. Admitiu que havia um pino pela metade (contendo "crack"), que estava consumindo. Após ter tragado, passou o cachimbo para Joilsson. É usuário de "crack" desde os 14 anos (arquivo digital - SAJ).

Como se vê, analisado o conjunto probatório, os elementos de convicção são frágeis para se concluir com a necessária segurança que a droga apreendida na posse dos réus destinava-se ao comércio ilícito.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida na posse dos réus (13 microtubos de "crack") é compatível com o consumo pessoal, ainda mais se considerarmos a massa líquida (os dois microtubos apreendidos na posse de Joilsson tinham massa líquida de 0,1 g, ou seja, 10 centigramas, enquanto que os 11 microtubos apreendidos na posse do acusado Rogério apresentaram massa líquida de apenas 0,6 g, ou seja, 60 centigramas, conforme se verifica às fls. 73). Além disso, a prisão dos réus e a apreensão das porções de "crack" foi ocasional (não houve delação, nem prévia investigação prévia) e a conclusão a que os policiais militares chegaram (de que um réu vendia a droga e o outro recolhia o dinheiro) não está amparada em elementos seguros de convicção.

Frisa-se, nesse ponto, que os dois policiais militares disseram que avistaram os réus e a terceira pessoa a cerca de 30 metros de distância (e à noite - vide horário na denúncia), tanto que nenhum deles soube informar que tipo de cédula foi entregue por esse terceiro ao réu Joilsson, sob o argumento, justamente, da distância.

Diante desse contexto, a conclusão dos policiais de que um dos réus teria entregue um microtubo de droga a terceira pessoa não se funda em elementos seguros, já que eles (policiais), à noite, estavam a uma distância considerável (30 metros) e esse suposto terceiro usuário nem sequer foi abordado e identificado, não se podendo concluir com certeza, portanto, que o objeto recebido pela terceira pessoa realmente fosse droga.

Duvidosa também a afirmação de um dos policiais de que todos os microtubos apreendidos estavam cheios de "crack". Isso porque se verifica que os 11 microtubos encontrados na posse de Rogério tinham massa líquida de apenas 0,6 g, ou seja, 60 centigramas, conforme laudo de constatação (fls. 72/74), quantidade que aparenta ser insuficiente para preencher os 11 microtubos apreendidos na posse do referido acusado.

É certo que Joilsson, ao contrário de Rogério, não apresentou justificativa muito convincente para a quantia em dinheiro que ele portava (R\$ 502,00). No entanto, também é certo que a acusação não logrou comprovar que esse dinheiro estava dividido em notas de valores pequenos, como costuma ocorrer nos casos em que são presos os pequenos traficantes.

Quanto a essa questão, cumpre ressaltar que Joilsson, em sua autodefesa, alegou que portava 4 notas de R\$ 100,00, duas de R\$ 50,00 e uma de R\$ 2,00. E nada há nos autos provando o contrário, ônus que cabia à acusação.

Quanto ao local ser ponto de tráfico, vale lembrar que, como salientou a digna Defesa, logicamente também é frequentado por usuários. E os antecedentes dos acusados, por si só, não podem levar à condenação pela traficância, que exige um juízo de certeza, e não de mera verossimilhança.

Destarte, não havendo elementos probatórios suficientes à configuração da traficância, necessária se faz a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, porquanto a dúvida milita em favor dos réus.

Não é necessário o aditamento da denúncia, pois esta descreveu os fatos relacionados à posse das drogas por ambos os réus.

Outrossim, a despeito de ter ocorrido a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas, não há razão para a remessa do feito ao Juizado

Especial Criminal, já que a competência é determinada no momento em que a ação é proposta (art. 87 do CPC).

Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Confira-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - Desclassificação do delito de tráfico para porte para uso, e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal - Impossibilidade - Regular recebimento da denúncia com realização de interrogatório do réu e audiência de instrução e julgamento, pelo Juízo suscitado - Incidência do artigo 87 do CPC - Conflito procedente - Competência do juízo suscitado.” (Conflito de Jurisdição nº 994.09.229663-0, Câmara Especial, Rel. Des. Martins Pinto, j. 10.5.2010, v.u.)

“APELAÇÃO CRIMINAL. Posse de drogas para consumo pessoal. Pretensão de reforma da r. sentença condenatória, para que seja designada audiência preliminar para oferecimento do benefício da transação penal. Apelante denunciado por tráfico de entorpecentes. Conduta desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal, com condenação. Rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao apelo.” (Apelação nº 0029435-75.2009.8.26.0625, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. José Damiano Pinheiro Machado Cogan, j. 27.10.2011, v.u.).

Também não é caso de se abrir vista dos autos ao Ministério Público para eventual proposta suspensão do processo ou de acordo de não persecução penal, porquanto, nas certidões de fls. 82/88 e 110/112, observa-se que ambos os réus são reincidentes e portadores de maus antecedentes.

Por fim, quanto ao delito de posse de droga para consumo pessoal, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a responsabilização criminal dos réus nos termos supramencionados, restando provada a autoria e a materialidade delitiva, além do inequívoco dolo, sendo de rigor a condenação deles pelo crime tipificado no art. 28, caput, da Lei nº 11343/2006.

A pequena quantidade de droga traz a presunção de que a finalidade desta seria à utilização pelos próprios acusados, ausentes elementos indicadores do tráfico ilícito de entorpecentes.

No entanto, essa pequena quantidade não é capaz de ilidir delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, sendo inaplicável, ao caso, o princípio da insignificância. Por menor que seja a quantidade de droga apreendida em poder do usuário, o delito está vinculado à propriedade do entorpecente, ao risco social e de saúde pública, e não à lesividade comprovada em cada caso concreto.

E mesmo que assim não fosse, no caso concreto, a quantidade de cocaína ("crack") encontrada em poder dos réus, em plena via pública, é suficiente para causar danos à saúde pública, justamente o que visa a lei proteger, já que se trata de droga de alto poder viciante.

Assim, comprovadas a materialidade delitiva e a autoria, e ausentes causas de exclusão da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, a condenação dos réus é medida que se impõe.

Passa-se à fixação e dosagem da pena.

Ambos os réus são reincidentes e portadores de maus antecedentes (fls. 82/88 e 110/112), bem como usuários, há vários anos, de droga de elevado potencial ofensivo à saúde pública ("crack"), o que leva à conclusão de que a mera advertência ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo são inadequadas à prevenção e repressão do delito.

Diante desse quadro, nos termos do art. 28, II, da Lei 11.343/06, ao réus se imporá a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 6 (seis) meses, em entidade a ser explicitada na fase executória.

Respeitado o entendimento do Ministério Público, não restou configurada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porquanto não há comprovação de que os réus se valeram da pandemia de COVID-19 para a facilitação do cometimento do crime.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, desclassificada a acusação (nos termos da fundamentação supra), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na presente ação penal e, por via de consequência, CONDENO os réus JOILSSON APARECIDO MAGALHÃES DA SILVA, qualificado às fls. 22/23, e ROGÉRIO RAIMUNDO DA SILVA, qualificado às fls. 20/21, ambos incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 6

(seis) meses, em instituição a ser indicada na fase de execução.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, observando-se, no entanto, por analogia, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, visto que os réus são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Diante da desclassificação da acusação e da condenação a pena de prestação de serviços, REVOGO a prisão preventiva de ambos os réus.

Com urgência, expeçam-se os respectivos alvarás de soltura clausulados em favor dos acusados.

Depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, feitas as anotações e comunicações de praxe, providencie-se o necessário ao cumprimento da pena imposta a cada um dos réus, bem como libere-se aos acusados o dinheiro apreendido (fl. 69: R\$ 64,00 a Rogério e R\$ 502,00 a Joilsson).

P.I.C.

Catanduva, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA